

1502793-13.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... acusado é multirreincidente (Autos nº 0003849-11.2005.8.26.0129 - tráfico; 0006562-17.2009.8.26.0129 - tráfico; 0000409-79.2017.8.26.0551 - furto; 1501505-98.2019.8.26.0320 - furto), de modo que majoro a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com pena pecuniária de 12 (doze) dias multa.

Houve confissão do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502793-13.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502793-13.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2235454/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19925100 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2036/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2235454 - 04º D.P. LIMEIRA, 2036/21/923 -

04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK MICHEL AVICCHIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ERIK MICHEL AVICCHIO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 23 horas, na esquina da Avenida Doutor Lauro Correa da Silva com a Rua Reverendo Alva Hardi, Vila Rocha, nesta cidade e comarca, ERIK MICHEL AVICCHIO, durante o repouso noturno, tentou subtrair para si cerca de 300 metros de cabos de

cobre de 25mm, avaliados aproximadamente em R\$5.000,00 (cinco mil reais), pertencente a Henrique Russo Fernandes somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, o réu estourou o cadeado do portão do barracão pertencente a vítima Henrique, aproveitando-se do horário de menor vigilância sobre os bens, e ingressou no imóvel. Com o uso de uma faca, o acusado cortou os cabos de cobre do relógio padrão e passou a puxá-los, com o fim de subtraí-los, contudo, durante a conduta criminosa, o réu foi surpreendido por Claudinei Alves da Silva, que passava defronte do imóvel e percebeu a prática delitiva, realizando a detenção do réu.

A guarda civil municipal foi acionada e o acusado foi conduzido até a delegacia, preso em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2021 (fls. 122/123).

O réu foi citado (fls. 142) e ofereceram defesa escrita (fls. 146/152).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 158/162).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunha, bem como interrogado o réu ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 32/35), auto de exibição e apreensão (fls. 36), laudo pericial do local (fls. 198/204), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o acusado disse que iria permanecer em silêncio (fls. 09).

Em Juízo, o réu disse que tem 39 anos. Trabalha como prensista. No dia em questão, passava pelo local, sua irmã mora ali perto. As pessoas têm o costume de jogar as coisas nele. Chamou a sua irmã, mas ela não saiu. A vizinha disse que sua parente não estava. Foi embora. Tentou furtar os fios de cobre. Não conseguiu levar nada. O vigilante apresentou uma faca, não se recorda de estar com o objeto. Não tinha qualquer ferramenta em seu poder. Iria revender esses fios por trinta reais o quilograma. Não deu tempo de tirar os fios de cobre. Já tem antecedentes criminais por furto e tráfico. Estava desempregado. Estava sozinho (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão judicial.

A vítima Henrique Russo Fernandes disse que é proprietário do barracão, do seu genitor. Deixou seu telefone com o vigilante. Já houve tentativa de furto em duas ocasiões. Contratou um vigilante. O barracão estava alugado, o inquilino iria

entrar naquele imóvel. O vigilante notou algo estranho e telefonou dizendo que conseguiu identificar quem mexia no local. Foi até a delegacia e assinou a queixa. O fio estava cortado, gastou com eletricitista. Teve que refazer a recolocação de fios e emenda dos cabos. Gastou em torno de dois mil reais. Foi furtado há dois anos da mesma forma, na outra ocasião gastou doze mil reais. Seu prejuízo seria de quinze mil reais se tivesse que trocar tudo. Dessa vez furtaram a fiação. Arrombaram o cadeado, teve que fazer uma grade nova. O corte do fio é do fato relativo a esse processo. Dessa vez tentaram pegar os fios (mídia).

Em casos como o presente, a palavra da vítima, que não tinha qualquer intenção de prejudicar injustamente o acusado, é de muito relevo.

"(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância" (...) RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

"Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

A testemunha Claudinei Alves da Silva contou que trabalhava como vigilante. Não estava trabalhando naquele dia. Saiu com sua esposa e ao atravessar a avenida viu um rapaz em frente ao padrão elétrico. Desconfiou da ação dele. Viu que a frente do padrão estava destruída. Pediu ajuda da guarda municipal. O furtador já havia cortado todos os fios. Ele tinha uma faca de grande porte em seu poder. Teve dano em um cadeado. Indagado, o réu disse que jogou na parte debaixo. Os cabos já estavam cortados. Não teve como o acusado negar o que ocorreu. Os fatos ocorreram por volta das onze horas da noite. A faca estava em poder do réu, ele estava cortando os fios de frente ao padrão. Não viu o denunciado arrombando, nem ele entrando. O réu disse que jogou parte do padrão ao lado do barracão. Acredita que só de puxar o portão iria estourar o cadeado, não precisa de ferramenta (mídia).

O guarda civil municipal Alex André Mendes de Brito, quando ouvido na delegacia, disse que foi acionado para comparecer a uma ocorrência de tentativa de furto de cabos elétricos em um barracão. Ao chegar Claudinei informou que avistou o acusado puxando fios de força pelo relógio de força. Claudinei informou também que com o réu foi encontrado uma faca (fls. 07).

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a guarda municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são

manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10)(...) (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).
Pois bem.

Com o uso de uma faca, o acusado cortou os cabos de cobre do relógio padrão e passou a puxá-los, com o fim de subtraí-los, contudo, durante a conduta criminosa, o réu foi surpreendido pelo vigilante noturno.

Verificou-se que o réu danificou o cadeado, o relógio energia do local e cortou a fiação padrão, visando à subtração de fios de cobre, porém foi surpreendido pelo vigilante. Houve prisão em flagrante.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de furto tentado imputado.

É sabido que o delito de furto se consuma com a posse sobre a coisa, ainda que por um breve espaço de tempo, não se exigindo que o agente consiga a posse mansa e pacífica, como antes se entendia. Trata-se, portanto, de adoção da teoria da amotio (cf. STJ, AgRg no REsp 1483770/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

No caso dos autos, todavia, o crime não se consumou, pois o réu sequer obteve a posse tranquila dos bens que pretendia subtrair, eis que surpreendido pelo vigilante quando ainda estava no local dos fatos, antes mesmo de fugir em poder da coisa.

Ressalto, ainda, que a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa resultou comprovada, fato este ratificado pelo laudo pericial do local que apontou amolgadura no suporte metálico do cadeado, além de danos na canaleta metálica utilizada para organizar a fiação (laudo de fls. 198/204).

É caso de incidência da causa de aumento de pena do furto noturno, uma vez que o crime se deu à noite e em período de descanso normal das pessoas, em que há menor vigilância nas casas, comércio, ruas, praças e zonas rurais.

A lei penal vigente não faz qualquer exigência de que o furto se dê em local habitado para que tenha incidência a causa de aumento de pena do furto noturno, não podendo o intérprete fazer exigência que a lei penal não faz.

Como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Incide a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. 2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus denegado”. (STJ, HC 191.300/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012).

Anote-se, ainda, até mesmo, a viabilidade jurídica da ocorrência do furto noturno-qualificado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do afirmado, a decisão agravada está sim em absoluta consonância com a linha de raciocínio desenvolvida por esta Corte na apreciação do recurso especial representativo da controvérsia 1.193.194/MG, ocasião em que se decidiu pela compatibilidade do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado. 2. Desse modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do raciocínio jurídico adotado por este Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte, verifica-se não haver, também nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 3. Assim, à míngua de argumentos robustos o bastante para superar os fundamentos da decisão agravada, mantenho-a incólume pelos seus próprios termos. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AREsp 741.482/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 08/09/2015, DJe 14/09/2015).

“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminoso em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos.” (STJ, HC 306.450/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

Não se acolhem também as versões de crime impossível ou desistência voluntária.

O crime impossível somente se configura quando, pela ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, não se concretiza o resultado lesivo. Mas, para tanto, necessário que o meio empregado seja ineficaz ou o objeto seja impróprio, o que não foi o caso dos autos. Mesmo frustrado o proveito patrimonial esperado pelo furtador, houve crime de furto tentado no caso em tela, não havendo absoluta ineficácia do meio ou do objeto.

A desistência voluntária, o arrependimento eficaz e a tentativa apresentam em comum características de ordem objetiva e de conotação subjetiva. Nos três institutos, ocorre uma ação realizada pelo agente, cuja vontade, de acordo com o plano previamente esboçado, está dirigida à produção de um resultado ilícito que não

chegou, contudo, a consumir-se. A partir daí, no entanto, os institutos se distinguem. A consumação não é alcançada por razões diversas: na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente; na desistência e no arrependimento eficaz, por manifestação de vontade do agente.

No caso, o que frustrou a ação do réu é que ele foi surpreendido pelo vigilante. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, e não por manifestação do acusado.

E nem se alegue a insignificância da conduta, para sustentar sua atipicidade. A legislação penal brasileira não consagra o "princípio da insignificância" ou o da "bagatela". A ação do acusado envolveu bem que conta com valor economicamente apreciável (fios de cobre), de réu reincidente e portador de maus antecedentes, consolidando a tipicidade do ato também em sua dimensão material, conforme julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça que segue abaixo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias destacaram os maus antecedentes e a reincidência específica do réu - que ostenta duas condenações definitivas anteriores pelos crimes de furto e de roubo - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp 1673509/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO. (...) II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. III - In casu, não se tem como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com quatro condenações já transitadas em julgado. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância (...)" (STJ, AgRg no HC 623.343/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE (...) 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. Evidenciado que o recorrente, além de ser reincidente específico, é possuidor de

maus antecedentes (e, ainda, em poucos dias praticou dois delitos contra o patrimônio em face da mesma vítima), resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, além de demonstrar o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1803543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Portanto, não é recomendável ou justo premiar o réu com a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva não tenha grande valor de mercado.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o bem de valor insignificante. É imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Aquele, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se o princípio da insignificância. Este, eventualmente, pode caracterizar o privilégio inculcado no artigo 155, § 2º, do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta.

Registre-se que, eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 1, parte geral: arts. 1º a 120. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 358).

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é portador de maus antecedentes (Autos nº 0002036-70.2010.8.26.0129, 0005428-81.2011.8.26.0129 e 0018164-87.2004.8.26.0320 - fls. 47/56).

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período

depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Por esse argumento, atendendo aos critérios norteadores previstos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, eis que presentes os maus antecedentes, fixando a pena em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça permite, em caso de multiplicidade de qualificadoras no delito de furto, a consideração desta pluralidade em dosimetria da pena:

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 2. Na espécie, a pena-base foi aplicada, de modo proporcional, 4 (quatro) meses acima do mínimo legal em conta das circunstâncias do furto, destacando a sentença o extraordinário esforço físico e destreza aplicados pelo réu para alcançar o telhado da casa que invadira, tudo a revelar o acentuado dolo da conduta. 3. A dosimetria penal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Casa a qual autoriza, diante da presença de dois elementos que qualificam o crime, que um deles seja utilizado para a tipificação e, outro, como circunstância judicial desfavorável. 4. No caso, o rompimento de obstáculo, consubstanciado na destruição das telhas e da clarabóia da casa, foi acolhido como qualificadora, ao passo que a escalada, valorada como circunstância judicial negativa. 5. Ordem denegada". (STJ, HC 206.427/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011).

Na segunda fase, o acusado é multirreincidente (Autos nº 0003849-11.2005.8.26.0129 - tráfico; 0006562-17.2009.8.26.0129 - tráfico; 0000409-79.2017.8.26.0551 - furto; 1501505-98.2019.8.26.0320 - furto), de modo que majoro a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com pena pecuniária de 12 (doze) dias multa.

Houve confissão do acusado e demonstração de arrependimento. Todavia, não há que se falar em compensação integral da agravante com a atenuante.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

No caso em julgamento, todavia, a multirreincidência inviabiliza a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a

Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase da dosimetria, aumento a pena em 1/3 devido ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno, fixando a pena em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa.

Por fim, o delito de furto não se consumou, sendo certo, no entanto, que o acusado percorreu pequena parte do iter criminis, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Saliento ter aplicado o redutor máximo, uma vez que não chegou sequer a ocorrer subtração, sem qualquer apossamento da coisa a ser furtada.

"Em casos de tentativa que não chega a haver subtração, a diminuição, pela insipiência da ação desencadeadora, deve ser de 2/3; se ocorrer o apossamento da "res" pelo furão, sem que este chegue a se afastar do local, a redução aplicável é a de metade da pena-base; e se a subtração ocorre, o larápio logrando afastar-se do local, mas sem alcançar a posse tranquila do material, o decréscimo observável será o de 1/3, até porque, se alcançada a posse imperturbada do produto do ilícito, já se estará diante de furto consumado" (TACRIM-SP - Rel. Juiz Bittencourt Rodrigues - JUTACRIM 87/222)

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do acusado.

Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, além de se tratar de crime de furto tentado, o regime inicial deverá ser o semiaberto, sob a luz do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Como o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, a folha de antecedentes demonstra que a imposição de medidas alternativas, como as penas restritivas de direitos, não trará o caráter preventivo da pena.

Sendo assim, afasto a possibilidade de substituição da pena corporal, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, por não se mostrar medida socialmente adequada.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois há apenas o relato da vítima em audiência, sem qualquer prova documental que justifique o valor por ela mencionado, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de instrução específica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado ERIK MICHEL AVICCHIO, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Não cabe a substituição por penas restritivas e nem por sursis.

O réu poderá recorrer em liberdade, na medida em que já se encontra preso desde 29 de agosto de 2021. Ademais, já atingiu lapso para progredir para o aberto. Daí porque entendo que ausentes os requisitos da preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Deixo de aplicar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do CPP. Anote-se

que eventual direito do réu à detração do tempo que permaneceu preso durante o processo é matéria a ser postulada por ocasião da execução da sentença, uma vez que naquela oportunidade será computado o tempo de prisão cautelar ou em razão de flagrante na pena a ser cumprida. Vale dizer, como a detração integra a execução da pena, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.210/84.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's, observada a gratuidade processual em razão de ser defendido pela Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA